



Roj: **STS 5816/2025 - ECLI:ES:TS:2025:5816**

Id Cendoj: **28079130022025100327**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **2**

Fecha: **11/12/2025**

Nº de Recurso: **5203/2023**

Nº de Resolución: **1628/2025**

Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**

Ponente: **MIGUEL DE LOS SANTOS GANDARILLAS MARTOS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **TEAC, 8-10-2019 (RG 9196/2012 y 519/2016),
SAN 2530/2023,
ATS 9250/2024,
STS 5816/2025**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1.628/2025

Fecha de sentencia: 11/12/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 5203/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 21/10/2025

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

Procedencia: AUD.NACIONAL SALA C/A. SECCION 2

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por: AFJ

Nota:

R. CASACION núm.: 5203/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1628/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.^a Esperanza Córdoba Castroverde

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.^a Sandra María González de Lara Mingo

D.^a María Dolores Rivera Frade

En Madrid, a 11 de diciembre de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación núm. 5203/2023, interpuesto por la Administración General del Estado, representada por el abogado del Estado, contra la sentencia de fecha 5 de mayo de 2023, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso interpuesto por la aquí demandada R+V LEBENSVERSICHERUNG. A.G, contra las resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición dictadas por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT.

Comparece como parte demandada la entidad R+V LEBENSVERSICHERUNG. A.G, representada por el procurador don Antonio Miguel Ángel Araque Almendros.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El objeto del presente recurso lo constituye la sentencia dictada el 5 de mayo de 2023, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso nº 883/2019, interpuesto por la entidad alemana R+V Lebensversicherung, A.G., contra la denegación de la solicitud de ingresos indebidos formulada sobre las retenciones practicadas a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), correspondientes a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente sobre los dividendos obtenidos de sus inversiones en participaciones de sociedades españolas, cuyo Fallo decía: «*[E]stimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D. Antonio Miguel Ángel Araque Almendros, en nombre y representación de R+V LEBENSVERSICHERUNG A.G, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 8 de octubre de 2019 (RG 9196/2012 y 519/2016); la cual anulamos por no ser ajustada a Derecho, en los términos que se infieren del Fundamento de Derecho Cuarto y con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración. Con imposición de costas a la parte demandada[...]*».

SEGUNDO.-Por el abogado del Estado, en la representación que ostenta, se presentó escrito ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, preparando recurso de casación contra la mencionada sentencia, el cual se tuvo por preparado mediante Auto de dicha Sala de fecha 3 de julio de 2023, emplazando a las partes personadas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por plazo de 30 días.

TERCERO.-Mediante Auto dictado el 10 de julio de 2024 por la Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se admitió a trámite el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y se acordó la remisión de las actuaciones para su tramitación y decisión a la Sección Segunda de este Tribunal.

La representación procesal de la parte recurrente, Administración General del Estado, interpuso recurso de casación en virtud de lo acordado en Diligencia de Ordenación de fecha 15 de julio de 2024, en el cual concluye solicitando «*[q]ue teniendo por presentado este escrito y por interpuesto el recurso de casación, previos los trámites oportunos, dicte sentencia por la que estime el recurso revocando la Sentencia recurrida en los aspectos y términos expresados en el apartado 3 del presente escrito [...]*».

CUARTO.-Dado traslado para oposición a la parte recurrida, se presentó escrito en fecha 19 de noviembre de 2024 en el que solicitaba: «*[q]ue admita este escrito y tenga por formulada oposición al recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 883/2019 y acuerde su desestimación, con imposición de las costas causadas a la parte recurrente, al amparo del artículo 93.4 LJCA [...]*».



QUINTO.-De conformidad con lo previsto en el artículo 92.6 de la Ley de esta Jurisdicción, y considerando innecesaria la celebración de vista pública, mediante providencia de fecha 12 de diciembre de 2024, quedaron las presentes actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo.

Mediante providencia de fecha 19 de septiembre de 2025, se designó magistrado ponente al Excmo. Sr. D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos y se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 21 de octubre de 2025, fecha en que comenzó su deliberación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resolución impugnada y antecedentes relevantes

1.1.-Es objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada el 5 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 883/2019, interpuesto por la entidad R+V Lebensversicherung, A.G., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) de 8 de octubre de 2019, que confirmó la denegación de la solicitud de ingresos indebidos formulada sobre las retenciones practicadas a cuenta del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR), correspondientes a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente sobre los dividendos percibidos de sus inversiones en participaciones de sociedades españolas.

1.2.-R+V Lebensversicherung, A.G., es un entidad aseguradora alemana con residencia fiscal en Alemania, y solicitó a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), el día 20 de febrero de 2015, la devolución de las cantidades que le fueron retenidas a cuenta del IRNR, ejercicios 2011 y 2013, por sus inversiones en acciones de sociedades españolas. El mismo día y de manera simultánea presentó rectificación de las autoliquidaciones.

1.3.-La AEAT, notificó a la solicitante las propuestas de liquidación con las que inició los correspondientes procedimientos de comprobación limitada. Tras el oportuno trámite de alegaciones, se le notificó los días 3 de junio y 1 de octubre de 2015, resoluciones con liquidación provisional desestimando las solicitudes de devolución porque *«[E]ste principio, no puede justificar que se admita la deducibilidad de las provisiones técnicas en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, porque supondría un trato discriminatorio para las entidades que obtuvieran rentas solo en su Estado de residencia. [...]»*.

1.4.-Contra las liquidaciones se dedujo recurso de reposición que fue desestimado formulando reclamaciones económico-administrativas.

1.5.-Contra el acuerdo desestimatorio del TEAC de 8 de octubre de 2019, se interpuso el recurso contencioso-administrativo núm. 883/2019, que fue acogido favorablemente por la sentencia objeto del presente recurso de casación.

En síntesis, la cuestión litigiosa se centró en la acreditación del vínculo económico directo e indisoluble de las provisiones con la actividad realizada en España. La Sala de instancia cuestionó el proceder de la Administración desde la óptica del principio de buena administración cuando, al igual que el TEAC, consideró insuficiente la prueba aportada por la entidad aseguradora sin indicar cuál sería la realmente e idónea, o los estándares de prueba a que se supeditaría la obtención de la devolución instada. Concluyó que la recurrente justificó la vinculación exigible entre los dividendos percibidos en territorio español y las provisiones técnicas que pretendía deducirse.

SEGUNDO.- Cuestión de interés casacional

2.1.-Por auto de 10 de julio de 2024 se le pregunta a la Sala para la formación de doctrina *«[D]eterminar si las entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que solamente llevan a cabo en España inversiones de carácter financiero, de las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, puede considerarse, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 del TRLIRNR, por remisión a la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) pueden deducirse por estar relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España. [...]»*.

2.2.-Se identificaron como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación, los artículos 24.6 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y 38 del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

TERCERO.- Alegaciones de las partes

3.1.-El abogado del Estado considera que la sentencia incurre en infracción del artículo 24.6 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (LIRNR), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las normas europeas y españolas reguladoras de la actividad aseguradora y del artículo 38 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.

Niega que exista un vínculo directo e indisociable de la provisión técnica con la actividad realizada por la aseguradora en España, porque no acepta que la mera inversión financiera en sociedades cotizadas españolas realizada por una aseguradora establecida en otro Estado miembro constituye actividad aseguradora. Su actividad inversora en España no se hizo al amparo de los artículos 78, 85 y 86 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre (LOSSP), se limitó a invertir en acciones emitidas por sociedades españolas.

También cuestiona la relación directa de la provisión técnica con los rendimientos que la recurrente obtuvo en España, y no se trata de una mera cuestión de prueba como dijo la sentencia, sino de la correcta interpretación del artículo 24.6 de la LIRNR. Estamos ante una provisión técnica comparable a la provisión de participación en beneficios y para extornos la prevista en el artículo 38 del ROSSP, con ausencia de toda relación directa entre este tipo de provisiones y los dividendos. No se trata de un supuesto equiparable a los United Linked a los que se le aplica el artículo 37 del ROSSP.

Afirma que las a las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia (C-342/10; 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17) y 17 de septiembre de 2015, Miljoen (asuntos acumulados C-10/14, C-14/14 y C-17/14) avalan la interpretación que hizo la Administración.

3.2.-R+V Lebensversicherung, A.G., tras un extenso relato de lo acontecido y un resumen de los motivos invocados, considera que la sentencia no infringió el artículo 26.4 de la LIRNR, en relación con las normas europeas y españolas reguladoras de la actividad aseguradora y, en particular, con el artículo 38 ROSSP, y que fue acorde con la interpretación conforme a la doctrina del TJUE, en concreto con la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen.

El artículo 24.6 de la LIRNR permite considerar como gastos fiscalmente deducibles para determinar la base imponible en el IRNR correspondiente a las rentas obtenidas en territorio español, todos los gastos fiscalmente deducibles para determinar la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades *«[s]iempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España [...]»*. La interpretación de este doble requisito no puede hacerse de modo que consientan la discriminación entre entidades aseguradoras con residencia fiscal en España y las residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Si una entidad aseguradora con residencia fiscal en España puede invertir en sociedades cotizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea en el que no esté establecida y, por ende, percibir dividendos, sin que nadie le discuta la deducibilidad como gasto fiscal de las provisiones técnicas que haya dotado en la cuantía mínima exigida por las normas sectoriales aplicables, a efectos del cálculo de la base imponible del IS, resulta discriminatorio negar ese misma deducción de las provisiones técnicas comparables a los efectos del cálculo de la base imponible del IRNR a la no residente.

Afirma que existe un vínculo directo e indisociable de la provisión técnica con la actividad realizada por mi representada en España. Advierte que la disociación entre las actividades propias de una entidad de seguros, en actividades aseguradoras y en actividades inversoras, no se realiza cuando la entidad aseguradora tiene su residencia fiscal en España. Las inversiones sí forman parte de su actividad como una entidad aseguradora, porque es una exigencia de los contratos de seguros suscritos y son sometidas a supervisión. No se puede restringir la actividad de la aseguradora a la asunción de prima a cambio de asumir riesgos.

Sostiene que hay relación directa entre una provisión técnica de participación en beneficios y los rendimientos obtenidos por mi representada en España. Tras reproducir unos pasajes de la resolución del TEAC explica cómo, acertadamente, la sentencia vino a reconocer que la existencia de vinculación entre los dividendos y la provisión del artículo 38 ROSSP, relegando el debate a un problema de gestión y de prueba.

Las sentencias del TJUE de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, y 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, aunque referidas a fondos de pensiones, avalan la interpretación de la Sala de instancia.

CUARTO.- Criterio de la Sala



El presente recurso ha sido deliberado el mismo día que el núm. 6201/2023, resuelto por la sentencia de fecha 10 de diciembre de 2025, ponente Excmo. Sr. don Isaac Merino Jara, a cuyos fundamentos nos remitimos por abordar un cuestión idéntica a la que aquí nos ocupa y por respeto a la unidad de doctrina.

Decíamos que: «[E]l presente recurso tiene grandes similitudes con el abordado por la sentencia 1463/2025, de 17 de noviembre, recaída en el rec. cas. 5786/2023, de ahí que, por seguridad jurídica y unidad de doctrina, nos remitimos a ella, reproduciendo parte de su contenido. Es necesario interpretar el artículo 24 TRLIRN, relativo a la base imponible en relación con las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, que en su redacción aplicable disponía que: «6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 1.ª Para la determinación de la base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir los gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España [...]». Dicho precepto fue modificado por el artículo 2.5 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, pasando a tener el siguiente contenido: «6. Cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las siguientes reglas especiales: 1.ª Para la determinación de base imponible correspondiente a los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente, se podrán deducir: [...] b) En caso de entidades, los gastos deducibles de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en R. CASACION/6201/2023 37 España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. 2.ª La base imponible correspondiente a las ganancias patrimoniales se determinará aplicando, a cada alteración patrimonial que se produzca, las normas previstas en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III y en la Sección 6.ª del Título X salvo el artículo 94.1.a), segundo párrafo, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Lo dispuesto en este apartado se aplicará igualmente a los contribuyentes residentes en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria en los términos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal». Según se señala en su Preámbulo, la reforma obedeció a dar una mayor claridad y favorecer las libertades de circulación recogidas en el Derecho de la Unión Europea, a cuyo fin se distingue, para los contribuyentes no residentes sin establecimiento permanente, entre personas físicas o personas jurídicas, estableciendo, para cada uno de estos dos supuestos, los gastos deducibles para el cálculo de la base imponible, por remisión a la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, respectivamente. En ese punto conviene recordar que, en su escrito de interposición, la Abogacía del Estado manifiesta que la RTEAC asumió que la aseguradora tenía derecho a deducir los gastos deducibles de acuerdo con la LIRNR, siempre que el contribuyente acredite que están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. Es decir, según la propia Abogacía del Estado, la resolución recurrida no se basó en que las dotaciones a las provisiones no eran deducibles porque con arreglo a la norma vigente en el período relevante solo lo fueran los "gastos previstos en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas R. CASACION/6201/2023 38 Físicas" sino porque no se cumplían los requisitos de relación directa con los rendimientos obtenidos en España y de vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España; y esto por entender que ya antes de la reforma de 2014 el Derecho de la UE determinaba que, tratándose de personas jurídicas, los gastos deducibles eran los comparables a los propios del Impuesto sobre Sociedades ("IS"). Es decir, que a esta conclusión conducía la interpretación de la ley a la luz del Derecho de la UE y que la ulterior reforma respondía a una necesidad de aclaración más que a una efectiva ampliación de lo deducible. Por su parte, el artículo 13.4 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, y también el artículo 14.7 de la vigente Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, otorgan la calificación de gasto fiscalmente deducible para la determinación de la base imponible de este impuesto, al que están sometidas las entidades aseguradoras con residencia fiscal en España, a los gastos relativos a las provisiones técnicas, sin distinción entre ellas, hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. La redacción de ambos es la misma. Concretamente es la siguiente: «los gastos relativos a las provisiones técnicas realizadas por las entidades aseguradoras, serán deducibles hasta el importe de las cuantías mínimas establecidas por las normas aplicables. Con ese mismo límite, el importe de la dotación en el ejercicio a la reserva de estabilización será deducible en la determinación de la base imponible, aun cuando no se haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cualquier aplicación de dicha reserva se integrará en la base imponible del período impositivo en el que se produzca. Las correcciones por deterioro

de primas o cuotas pendientes de cobro serán incompatibles, para los mismos saldos, con la dotación para la cobertura de posibles insolvencias de deudores.». Por su parte, el artículo 29 (Concepto y enumeración de las provisiones técnicas) del Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se R. CASACION/6201/2023 39 aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), en la redacción a la sazón vigente, establece: «1. Las provisiones técnicas deberán reflejar en el balance de las entidades aseguradoras el importe de las obligaciones asumidas que se derivan de los contratos de seguros y reaseguros. Se deberán constituir y mantener por un importe suficiente para garantizar, atendiendo a criterios prudentes y razonables, todas las obligaciones derivadas de los referidos contratos, así como para mantener la necesaria estabilidad de la entidad aseguradora frente a oscilaciones aleatorias o cíclicas de la siniestralidad o frente a posibles riesgos especiales. La corrección en la metodología utilizada en el cálculo de las provisiones técnicas y su adecuación a las bases técnicas de la entidad y al comportamiento real de las magnitudes que las definen, serán certificadas por un Actuario de Seguros, sin perjuicio de la responsabilidad de la entidad aseguradora. En el caso de que se elaboren balances con periodicidad diferente a la anual, el cálculo y la constitución de las provisiones técnicas se efectuarán aplicando los criterios establecidos en este Reglamento con la adaptación temporal necesaria. 2. Las provisiones técnicas son las siguientes: a) De primas no consumidas. b) De riesgos en curso. c) De seguros de vida. d) De participación en beneficios y para extornos. e) De prestaciones. f) La reserva de estabilización. g) Del seguro de decesos. h) Del seguro de enfermedad. i) De desviaciones en las operaciones de capitalización por sorteo. 3. Las provisiones técnicas aplicables al reaseguro aceptado y cedido serán las recogidas en los párrafos a) a e), ambas inclusive, del apartado anterior, exceptuando, en cuanto al cedido, la contemplada en el párrafo b). Igualmente será aplicable la provisión contemplada en el párrafo f) anterior para las aceptaciones en reaseguro de riesgos catastróficos. El importe correspondiente a las provisiones técnicas del reaseguro aceptado y cedido deberá calcularse en la forma prevista en este Reglamento, teniendo en cuenta, en su caso, las condiciones específicas de los contratos de reaseguro suscritos. El cálculo de las provisiones por operaciones de reaseguro aceptado, tomará como base los datos que facilite la entidad cedente, incrementándolos en cuanto proceda de acuerdo con la experiencia de la propia entidad. 4. Las entidades exclusivamente reaseguradoras deberán constituir provisiones técnicas, incluida la reserva de estabilización, suficientes para el conjunto de sus actividades.». R. CASACION/6201/2023 40 El propio RTEAC entendió que la aseguradora pretendía la deducción de la dotación a una provisión que, con independencia de su denominación y régimen en Alemania, resulta equivalente a una de las provisiones técnicas reguladas en el Derecho español aplicable a las entidades aseguradoras residentes, la "provisión de participación en beneficios y para extornos", incluida en la enumeración del art. 29.2 regulada en el art. 38, ambos del ROSSP. También es necesario interpretar el art. 38 ROSSP, referente a la provisión de participación en beneficios y para extornos, que determina que: «1. Esta provisión recogerá el importe de los beneficios devengados en favor de los tomadores, asegurados o beneficiarios y el de las primas que proceda restituir a los tomadores o asegurados, en su caso, en virtud del comportamiento experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no hayan sido asignados individualmente a cada uno de aquéllos. 2. Los seguros distintos del seguro de vida que garanticen el reembolso de primas bajo determinadas condiciones o prestaciones asimilables incluirán en esta provisión las obligaciones correspondientes a dicha garantía, calculadas conforme a las siguientes normas: Se incluirán en la provisión todas las obligaciones por los contratos que sobre la base de la información existente al cierre del ejercicio sean susceptibles de dar lugar a las prestaciones citadas. La provisión a dotar comprenderá el importe de las primas a reembolsar o prestaciones a satisfacer imputables al período o períodos del contrato ya transcurridos en el momento de cierre del ejercicio». En sus alegaciones casacionales las partes cuestionan la interpretación de la normativa española aplicable a tenor de la jurisprudencia sentada por el TJUE. La sentencia de dicho TJUE de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22 , EU:C:2024:932), resulta del máximo interés. En ella, se contienen referencias a doctrina consolidada del propio Tribunal que permiten conocer su visión jurisprudencial. R. CASACION/6201/2023 41 Comenzaremos reproduciendo dos de sus apartados: «28. De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE , apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencias de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17 , EU:C:2019:960, apartado 48, y de 29 de julio de 2024, Keva y otros, C39/23 , EU:C:2024:648, apartado 40 y jurisprudencia citada). 31. Cuando un Estado miembro practica una retención en la fuente sobre los dividendos distribuidos por sociedades establecidas en ese Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, a efectos de determinar si una legislación de dicho Estado miembro es compatible con el artículo 63 TFUE , apartado 1, corresponde al órgano jurisdiccional nacional de que se trate, único que puede examinar los hechos del litigio del que está conociendo, verificar si la aplicación de una retención en la fuente a los dividendos distribuidos a una sociedad no residente tiene como resultado, en definitiva, que dicha sociedad soporte una carga impositiva mayor, en el mismo Estado miembro, que la que soportan los residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14 , C-14/14 y C-17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 48). » También nos importan determinados



apartados de la sentencia de 20 de junio de 2024, Faurécia (C-420/23, EU:C:2024:534) que sintetizan, en parte, la jurisprudencia sobre el marco jurídico primario de la libertad de circulación, concretamente, los siguientes: «21 El artículo 63 TFUE, apartado 1, prohíbe con carácter general las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros. Las medidas prohibidas por esa disposición, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que puedan disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (sentencia de 27 de abril de 2023, L Fund, C-537/20, EU:C:2023:339, apartado 42 y jurisprudencia citada). 28.No obstante, con arreglo al artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), lo dispuesto en el artículo 63 TFUE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya R. CASACION/6201/2023 42 situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital. 29 Según reiterada jurisprudencia, el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en que residan o del Estado miembro en el que inviertan sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22, EU:C:2023:880, apartado 27 y jurisprudencia citada]. 30 En efecto, las diferencias de trato permitidas por el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), no deben constituir, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo, ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general [sentencia de 16 de noviembre de 2023, Autoridade Tributária e Aduaneira (Plusvalías por transmisión de participaciones), C-472/22, EU:C:2023:880, apartado 28 y jurisprudencia citada]. ». » Igualmente, resulte de interés los apartados 48 y 49 de la sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en tanto en cuanto se refirieren al requisito de la vinculación entre el gasto, pretendidamente deducible, y la actividad realizada. En ellos se declara: «48 De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imponderables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünewald, C559/13, EU:C:2015:109, apartado 29; de 8 de noviembre de 2012, Comisión/Finlandia, C342/10, EU:C:2012:688, apartado 37; de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros, C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608, apartado 57, y de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, C-641/17, EU:C:2019:960, apartado 74). 49 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, presentan un vínculo directo con la actividad considerada los gastos ocasionados por esta y necesarios por tanto para su ejercicio (sentencias de 24 de febrero de 2015, Grünewald, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 30 y jurisprudencia citada; de 13 de julio de 2016, Brisal y KBC Finance Ireland, C- R. CASACION/6201/2023 43 18/15, EU:C:2016:549, apartado 46, y de 6 de diciembre de 2018, Montag, C-480/17, EU:C:2018:987, apartado 33).» En principio, las provisiones técnicas no parecen poder relacionarse con la percepción, en sí misma, de los dividendos. En términos semejantes a esta cuestión ya se ha planteado otra que ha sido abordada en la citada sentencia de 7 noviembre de 2024, XX (Contratos denominados unit-linked) (C-782/22, EU:C:2024:932), en relación con la posibilidad de deducir de su beneficio imponible relativo a los dividendos las cargas correspondientes a sus clientes en el marco de contratos de seguro "en unidades de cuenta". En dicha sentencia, apartados 54 a 57, se declara: «54 En efecto, en los apartados 55 y 81 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), posterior a la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Miljoen y otros (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que un fondo de pensiones no residente que destine los dividendos percibidos a dotar provisiones por las pensiones que deberá abonar en el futuro, ya sea deliberadamente o de conformidad con la normativa vigente en su Estado de residencia, se encuentra en una situación comparable a la de un fondo de pensiones residente en relación con una normativa nacional en virtud de la cual, para calcular el impuesto sobre sociedades, la percepción de dividendos por ese fondo de pensiones residente da lugar a un incremento del resultado sujeto a tributación muy reducido, e incluso, en algunos casos, inexistente. Efectivamente, el Tribunal de Justicia señaló, en el mencionado apartado 55, que tal percepción conlleva un incremento proporcional de las provisiones técnicas y que únicamente se produce un incremento del resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones residente cuando los rendimientos de las inversiones extracontables no se trasladen al crédito de los distintos contratos de este último fondo de pensiones. 55 En los apartados 79 y 80 de la sentencia de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C-641/17, EU:C:2019:960), el Tribunal de Justicia consideró, en efecto, por una parte, que en el asunto que dio lugar a dicha sentencia existía una relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente y, por otra parte, que tal normativa nacional, que permitía la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes, facilitaba así la acumulación de capitales de tales fondos,



mientras que todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de R. CASACION/6201/2023 44 capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro. 56 Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que las obligaciones de los fondos de pensiones relativas a la inversión de las primas de seguro y a la afectación de los dividendos percibidos para provisionar las pensiones de jubilación pueden fundamentar la comparabilidad entre los fondos de pensiones residentes y no residentes a la luz de una normativa nacional que, mediante las modalidades de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades, permita eximir total o casi totalmente los dividendos percibidos por un fondo de pensiones residente, cuando exista una relación de causalidad entre la percepción de los dividendos y las cargas constituidas por dichas obligaciones y derivadas de la actividad de tales fondos. 57 En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien una sociedad como XX no constituye un fondo de pensiones, la actividad de esta se caracteriza por el hecho de que dicha sociedad invierte, en particular en acciones en los Países Bajos, para cubrir sus compromisos frente a sus clientes en el marco de contratos en unidades de cuenta y que los rendimientos obtenidos de la inversión por dicha sociedad conllevan la correspondiente modificación del valor de sus compromisos frente a los clientes en virtud de los contratos mencionados.» No cabe duda de la utilidad de las consideraciones que acabamos de reproducir. La intercambialidad de tales argumentos entre los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras, a los presentes efectos, resulta viable. La representación procesal de la Administración estatal no ha puntualizado qué objetivo persigue la deducción de las provisiones, pero está claro que se pretende, en última instancia, mantener la solvencia de las entidades. El único criterio de distinción entre residentes y no residentes en la normativa nacional se basa, realmente, en el lugar de residencia de la aseguradora. La libre circulación de capitales se opone a una normativa nacional que tome en cuenta los rendimientos brutos de los no residentes sin deducir las provisiones técnicas, mientras que los residentes tributan por rendimientos netos previa deducción de los gastos de las provisiones técnicas. R. CASACION/6201/2023 45 El auto de admisión establece la relevancia casacional en torno al art. 24.6 del TRLIRNR. Ambas partes procesales parten del presupuesto de que los dividendos repartidos por una entidad residente en España se consideran rentas de actividades o explotaciones económicas obtenidas y, por ello, sometidas a tributación en España, en manos de las entidades no residentes que operen en nuestro país sin mediación de un establecimiento permanente. Dicho de otra forma, están sujetas ex artículo 15, siendo un supuesto de renta obtenida en España (actual artículo 13.1.f). Las provisiones técnicas son gastos y como tales deducibles a efectos del impuesto de sociedades (art. 13 TRLIS y 14.7 LIS), siempre que hayan sido dotadas conforme a los criterios del citado Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en cuyo artículo 38 se recoge expresamente la provisión de participación en beneficios y para extornos. Dentro de este contexto normativo, cabe interpretar el artículo 24.6 del TRLIRNR y su aplicación a una provisión de semejante naturaleza. La Abogacía del Estado considera que este tipo de provisiones técnicas en el ramo de seguros no equivalen al desarrollo de actividad aseguradora, más bien, a su juicio, estamos en presencia de una mera colocación de capital, sin embargo, ello se compadece mal con el actual sistema de seguros amparado por la normativa española, particularmente, el art. 29 ROSSP, reproducido anteriormente. El funcionamiento general de las pólizas "unit linked" y las pólizas con participación en beneficios "no unit linked" resulta muy similar, a los efectos que ahora importan, dado que en ambos tipos existe un traslado económico de la rentabilidad producida por los dividendos a los tomadores de las pólizas, ya sea por soportar el tomador el riesgo económico de las inversiones (pólizas "unit linked"), o por haber acordado con los tomadores el traslado a ellos de una parte de la rentabilidad de los activos afectos a la póliza ("with profits"). R. CASACION/6201/2023 46 Una provisión técnica de participación en beneficios, no cabe caracterizarla como ajena al proceso productivo del sector asegurador, donde la solvencia resulta capital. Así lo expresa la propia ley del sector, hoy vigente, Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. cuando manifiesta en su preámbulo: «La Directiva Solvencia II supone un notable ejercicio de armonización que pretende facilitar el acceso y ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en la Unión Europea mediante la eliminación de las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros y, por tanto, el establecimiento de un marco legal dentro del cual las entidades aseguradoras y reaseguradoras puedan operar en un único mercado interior. La Directiva Solvencia II articula una concepción de la solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras basada en tres pilares que se refuerzan mutuamente. El primero, constituido por reglas uniformes sobre requerimientos de capital determinados en función de los riesgos asumidos por las entidades, en consonancia con los desarrollos alcanzados en materia de gestión de riesgos y con la evolución reciente en otros sectores financieros. Se adopta así para el sector asegurador europeo un enfoque basado en el riesgo, mediante la introducción de normas específicas sobre el capital económico. El segundo de los pilares está integrado por un nuevo sistema de supervisión con el objetivo de fomentar la mejora de la gestión interna de los riesgos por las entidades. El tercero se refiere a las exigencias de información y transparencia hacia el mercado sobre los aspectos clave de los riesgos asumidos por las entidades y su forma de gestión. Adicionalmente a la introducción del nuevo sistema de solvencia basado en el riesgo y de los cambios que ello requiere en la forma de gestión de las entidades y en la actuación de las autoridades supervisoras, la Directiva Solvencia II efectúa una consolidación, por refundición, del resto del ordenamiento europeo en materia



de seguros privados, salvo en lo referente al seguro de automóviles, incorporando los contenidos recogidos en las directivas que ya se habían transpuesto en su momento al Derecho español de seguros, como por ejemplo, la Directiva 2001/17/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros. El esquema ha sido completado con los desarrollos normativos y la medidas de ejecución derivadas de la nueva estructura de supervisión diseñada en este campo en la Unión Europea por el establecimiento de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, mediante el Reglamento (CE) n.º 1094/2010, de 24 de noviembre, del Parlamento Europeo y R. CASACION/6201/2023 47 del Consejo, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión, que le atribuye importantes facultades de coordinación y decisorias en materia de supervisión y ordenación de seguros y reaseguros, logrando una mayor armonización reguladora y una mejor coordinación internacional e intersectorial. Las disposiciones contenidas en esta Ley y en el reglamento que la desarrolle, resultado de la transposición de la Directiva Solvencia II, deben ser integradas con los desarrollos normativos y las medidas de ejecución dictadas por la Comisión Europea y por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) en un amplio conjunto de cuestiones como la valoración de activos y pasivos, provisiones técnicas, los fondos propios, el cálculo del capital de solvencia obligatorio, modelos internos, el capital mínimo obligatorio, las normas de inversión, el sistema de gobierno, el capital adicional, la información a efectos de supervisión, la transparencia de la autoridad supervisora, la solvencia de los grupos de entidades así como la determinación de la equivalencia de los regímenes de terceros países con las disposiciones de la Directiva Solvencia II. . » Este enfoque se constata en la jurisprudencia del TJUE, destacando la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos tres apartados: «48 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados (véanse, en particular, las sentencias de 10 de abril de 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, C-190/12, EU:C:2014:249, apartado 39, y de 22 de noviembre de 2018, *Sofina y otros*, C-575/17, EU:C:2018:943, apartado 23 y jurisprudencia citada).» "80 Una normativa nacional que permite la exención total o prácticamente total de los dividendos abonados a los fondos de pensiones residentes facilita así la acumulación de capital de dichos fondos, mientras que, tal y como señaló el Gobierno alemán en la vista, todos los fondos de pensiones están obligados, en principio, a invertir las primas de seguro en el mercado de capitales para generar ingresos en forma de dividendos que les permitan cumplir sus obligaciones futuras derivadas de los contratos de seguro. R. CASACION/6201/2023 48 108 Pues bien, tal como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, la adquisición de participaciones por un fondo de pensiones y los dividendos que percibe a este respecto sirven principalmente para mantener los activos y garantizar las provisiones que ha constituido gracias a una mayor diversificación y a una mejor distribución del riesgo al objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de pago de pensiones de jubilación frente a sus afiliados. Así pues, esta adquisición de participaciones y estos dividendos son, en primer lugar, un medio empleado por los fondos de pensiones para poder cumplir sus compromisos en materia de pensiones y no un servicio que preste dichos afiliados.» El art. 24.6 TRLIRNR no establece distinción alguna, habla literalmente de "gastos deducibles" y las provisiones técnicas lo son. El problema será, en consecuencia, determinar si las provisiones técnicas cuya deducción se pretende están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y si tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España. Entendemos que cabe establecer un vínculo directo por cuanto la dotación de esta provisión tiene su causa en la obligación de asignar a los tomadores/beneficiarios parte de los beneficios obtenidos por la entidad aseguradora, ya sea de los beneficios financieros derivados de todas o una parte de sus inversiones o de los técnicos vinculados a la siniestralidad de toda o parte de la cartera de seguros. Mientras la primera modalidad es típica de los seguros de vida-ahorro, la segunda es habitual en los seguros de viduages u otros seguros personales (enfermedad, accidentes). Esta conclusión está avalada en supuestos similares reconocidos por la jurisprudencia del TJUE: En ese sentido, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960), de la que reproducimos dos apartados: «74. En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación relativa a la diferente situación de los fondos de pensiones residentes y no residentes en cuanto a la posibilidad de que se tengan en cuenta las dotaciones a las provisiones para hacer frente a los compromisos en R. CASACION/6201/2023 49 materia de pensiones como gastos profesionales, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en lo que concierne a los gastos, como, por ejemplo, los gastos profesionales vinculados directamente a una actividad que ha generado rendimientos imposables en un Estado miembro, los residentes en este y los no residentes se encuentran en una situación comparable (véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 2011, *Schröder*, C-450/09, EU:C:2011:198, apartado 40; de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10, EU:C:2012:688, apartado 37, y de 24 de febrero de 2015, *Grünewald*, C-559/13, EU:C:2015:109, apartado 29).

79 Así pues, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que existe una



relación de causalidad entre la percepción de dividendos, el incremento de las provisiones matemáticas y de otras partidas del pasivo y la ausencia de incremento de la base imponible del fondo residente, en la medida en que los dividendos utilizados para las provisiones técnicas no incrementan el resultado sujeto a tributación del fondo de pensiones, extremo que fue confirmado por el Gobierno alemán en la vista. En efecto, según dicho Gobierno, una gran parte de los beneficios obtenidos a través de la inversión debe beneficiar al afiliado, lo que quiere decir que no pueden permanecer en el activo del fondo de pensiones y que los ingresos son la condición para el gasto en concepto de provisiones». Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, conforme al Derecho nacional, qué gastos se pueden considerar directamente vinculados a la actividad en cuestión. Precisamente, dentro de esa facultad de "apreciación" reconocida por la jurisprudencia comunitaria anteriormente transcrita, se encuentra la sentencia de instancia, quien procede a ponderar las circunstancias concurrentes tales como la correspondiente trazabilidad de las inversiones. La recurrente realizó un esfuerzo probatorio que ha sido valorado por el tribunal de instancia ponderando de manera razonada los elementos probatorios puestos a su disposición. R. CASACION/6201/2023 50 No está demás, reproducir el apartado 49 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de julio de 2016, *Brisal y KBC Finance Ireland*, C-18/15, EU:C:2016:549, en la que se declara que «el mero hecho de que dicha prueba ofrezca mayor dificultad, no es motivo suficiente para que un Estado miembro deniegue de forma absoluta a los no residentes, sujetos pasivos por obligación real, una deducción que concede a los residentes, sujetos pasivos por obligación real, puesto que no puede excluirse a priori que un no residente pueda aportar los justificantes pertinentes que permitan a las autoridades tributarias del Estado miembro de tributación comprobar, de manera clara y precisa, la existencia y la naturaleza de los gastos profesionales cuya deducción se solicita (véanse, por analogía, las sentencias de 27 de enero de 2009, *Persche*, C-318/07, EU:C:2009:33, apartado 53, y de 26 de mayo de 2016, *Kohll y KohllSchlesser*, C-300/15, EU:C:2016:361, apartado 55).» En nuestra sentencia 13 de noviembre de 2019, rec. cas. 3023/2018, nos hicimos eco de que el TJUE ha señalado que «las autoridades tributarias de un Estado miembro están facultadas para exigir al contribuyente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si se cumplen los requisitos de una ventaja fiscal prevista por la legislación pertinente y, por consiguiente, si procede conceder o no dicha ventaja. No obstante, el ejercicio de dicha autonomía fiscal de los Estados miembros debe hacerse respetando las exigencias que se derivan del Derecho de la Unión, especialmente las establecidas por las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, lo cual entraña que los potenciales beneficiarios no residentes no pueden estar sujetos a cargas administrativas excesivas que les impidan de forma efectiva beneficiarse del régimen fiscal de que se trata». La evolución de la normativa española, la jurisprudencia del TJUE y de esta misma Sala, avalan una interpretación favorable a la pretensión de las aseguradoras desde el prisma de la libertad de circulación de capitales. En resumen, como consecuencia de la dotación de las provisiones técnicas, las empresas residentes en España se benefician de un crédito fiscal, solicitando la devolución de las retenciones en exceso sufridas. Posibilidad que debe ser también concedida a las entidades aseguradoras no residentes sin establecimiento permanente: R. CASACION/6201/2023 51 En nuestra sentencia de 5 de junio de 2018, rec. cas. 634/2017 declaramos que: «la existencia de este trato discriminatorio, por contravenir el principio de libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE, ha sido concluyentemente admitida por el legislador en la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria, que incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 24 de la Ley del IRNR, como argumenta la sentencia de instancia. Como culminación de cuanto hemos expuesto, debemos afirmar que la vulneración del Derecho de la Unión Europea es aquí de doble signo: de un lado, en su aspecto material, porque las sociedades no residentes perceptoras de dividendos de empresas residentes son discriminatoriamente tratadas en relación con esas mismas empresas si fueran residentes, como consecuencia de que la base imponible del impuesto real se calcula en las primeras sobre el importe íntegro (artículos 23 de la Ley 41/1998 y 24 del Texto Refundido de 2004), sin posibilidad alguna de deducir los gastos o provisiones». De la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros* (C-10/14, C-14/14 y C-17/14, EU:C:2015:608), interesan los siguientes dos apartados: «64. Por consiguiente, es necesario distinguir las diferencias de trato permitidas en virtud del artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), de las discriminaciones prohibidas por el apartado 3 de ese mismo artículo. Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, para que una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal pueda considerarse compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso que la diferencia de trato afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o resulte justificada por razones imperiosas de interés general (véase la sentencia *Santander Asset Management SGIC y otros*, C-338/11 a C-347/11, EU:C:2012:286, apartado 23 y jurisprudencia citada). 67. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a partir del momento en residentes que un Estado miembro, de forma unilateral o por vía de convenios, somete al impuesto sobre la renta no sólo a los contribuyentes residentes sino también a los no residentes, por los dividendos que perciben de una sociedad residente, la situación de los mencionados contribuyentes no residentes se asemeja a la de los contribuyentes (véanse, en este sentido, las sentencias



*Denkavit Internationaal y Denkavit R. CASACION/6201/2023 52 France, C-170/05 , EU:C:2006:783, apartado 35; Comisión/Italia, C-540/07 , EU:C:2009:717 , apartado 52; Comisión/España, C-487/08 , EU:C:2010:310, apartado 51; Comisión/Alemania, C-284/09 , EU:C:2011:670, apartado 56, así como el auto Tate & Lyle Investments, C-384/11 , EU:C:2012:463 , apartado 31).» En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2019, *College Pension Plan of British Columbia* (C-641/17, EU:C:2019:960) son destacables los siguientes apartados: « 49 (...) el hecho de que un Estado miembro dispense a los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes un tratamiento menos favorable en comparación con el trato que se dispensa a los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes puede disuadir a las sociedades establecidas en un Estado miembro distinto de ese primer Estado miembro de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartado 33; de 22 de noviembre de 2012, *Comisión/Alemania*, C-600/10 , no publicada, EU:C:2012:737 , apartado 15, y de 2 de junio de 2016, *Pensioenfonds Metaal en Techniek*, C252/14 , EU:C:2016:402 , apartado 28). 50 Constituye un tratamiento menos favorable la aplicación a los dividendos abonados a fondos de pensiones no residentes de una carga impositiva mayor que la que soportan los fondos de pensiones residentes en relación con los mismos dividendos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, *Miljoen y otros*, C-10/14 , C-14/14 y C17/14 , EU:C:2015:608 , apartado 48). Lo mismo sucede cuando los dividendos pagados a los fondos de pensiones residentes se benefician de una exención total o parcial, mientras que los dividendos pagados a los fondos de pensiones no residentes se someten a una retención en origen definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2012, *Comisión/Finlandia*, C-342/10 , EU:C:2012:688, apartados 32 y 33). 51 Según se desprende de la resolución de remisión, en virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, los fondos de pensiones están sujetos, por lo que respecta a los dividendos que se les distribuyen, a dos regímenes de tributación diferentes, cuya aplicación depende de su condición de residente en el territorio del Estado miembro de la sociedad que distribuye los dividendos. 56 De ello se deduce que, debido a esta deducción de las provisiones correspondientes a los dividendos percibidos de la base imponible para el cálculo del impuesto sobre sociedades, R. CASACION/6201/2023 53 los dividendos percibidos por los fondos de pensiones residentes no incrementan dicha base imponible, o la incrementan de manera muy reducida. 63 Esta disposición debe interpretarse en sentido estricto, en la medida en que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en el que residen o del Estado miembro en el que invierten sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado FUE. En efecto, la excepción establecida en el artículo 65 TFUE , apartado 1, letra a), está limitada, a su vez, por el artículo 65 TFUE , apartado 3, que prescribe que las disposiciones nacionales a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo «no deberán constituir ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales y pagos tal como la define el artículo 63 [TFUE]» (sentencia de 10 de abril de 2014, *Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company*, C-190/12 , EU:C:2014:249, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).» El reconocimiento del carácter deducible de la provisión de participación en beneficios y para extornos regulada en el art. 38 del ROSSP, se enmarca dentro del principio general de adaptación de la normativa española al acervo legislativo y jurisprudencial comunitario, e impone que las personas jurídicas no residentes, pero que residan en países de la UE, para determinar la base imponible de los rendimientos que obtengan sin mediación de establecimiento permanente puedan deducir los gastos conforme a lo previsto en la LIS, ciertamente, siempre que se acredite, que los mismos están relacionados directamente con los obtenidos en España y que tienen un vínculo económico directo e indisoluble con la actividad realizada en España. Amparar un planteamiento como el auspiciado por la administración tributaria, supondría la introducción de distorsiones fiscales en directa colisión con la libre circulación de capitales del artículo 63 TFUE , esto es, consagrar un trato fiscal diferente por razón del lugar de residencia. No debemos olvidar, que el sistema asegurador ostenta un marco normativo armonizado (Directiva 2009/138/CE), y precisamente estamos ante un sector que precisa de ingente financiación, donde el flujo inversor entre los estados miembros resulta cada vez más indispensable para garantizar el sistema de coberturas y solvencia de la actividad aseguradora. R. CASACION/6201/2023 54 A mayor abundamiento, se insiste en que por la sentencia de instancia se estima la demanda puesto que se concluye que la entidad aseguradora ha realizado un esfuerzo probatorio serio y riguroso para acreditar la correlación del gasto que se pretende deducir con los ingresos obtenidos. [...]».*

QUINTO.- Fijación de doctrina

Por las idénticas razones, nos remitimos a la doctrina que se ha fijado en el fundamento de derecho cuarto de la citada sentencia, en el que acordamos que «[L]as entidades aseguradoras residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea que sólo realicen en España inversiones de carácter financiero, por las que obtienen rendimientos de capital mobiliario sin establecimiento permanente, pueden considerar, a los efectos de la deducibilidad de gastos prevista en el artículo 24.6 TRLIRNR, que los relativos a las provisiones técnicas (comparables con las previstas en el artículo 38 ROSSP y exclusivas de la actividad aseguradora) son fiscalmente

deducibles para evitar una discriminación contraria a la libre circulación de capitales del artículo 63.1 TFUE , en tanto en cuanto ha de entenderse que dichos gastos están relacionados directamente con los rendimientos obtenidos en España y tienen un vínculo económico directo e indisociable con la actividad realizada en España. [...]».

Esta doctrina nos conduce a la desestimación del recurso de casación y la confirmación de la sentencia de instancia.

SEXTO.- Costas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

1.-Reiteramos la doctrina recogida en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia de 10 de diciembre de 2025, RC 6201/2023.

2.-No haber lugar al recurso de casación núm. 5203/2023 interpuesto por la Administración General del Estado, representada y defendida por el abogado del Estado contra la sentencia dictada el 5 de mayo de 2023 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que estimó el recurso contencioso-administrativo núm. 883/2019, interpuesto por la entidad alemana R+V Lebensversicherung, A.G., contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 8 de octubre de 2019, relativa al impuesto sobre la Renta de no Residentes, sentencia que se confirma.

3.-No hacer imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.